

1501349-30.2020.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

REINALDO SMOLARI DOS SANTOS

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Reinaldo Smolari dos Santos, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1501349-30.2020.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501349-30.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

REINALDO SMOLARI DOS SANTOS

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Reinaldo Smolari dos Santos, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 97/98).

Determinou-se o processamento (fls. 104/107).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 145), apresentou resposta escrita (fls. 165/166). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 167/170) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 202).

Em audiência (fls. 205/207 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

A sentença penal foi proferida (fls. 208/226).

A parte ré recorreu (v. TA e fls. 228/233).

O Ministério Público não recorreu (v. TA).

A apelação foi recebida (v. TA).

O Ministério Público respondeu (fls. 241/242).

Os autos foram remetidos ao nosso E. Tribunal (fls. 251).

O Tribunal ad quem julgou a apelação (fls. 269/280).

O processo transitou em julgado (fls. 310).

II – DOS FUNDAMENTOS

2.1Da determinação com efeito rescindente

A Defesa ajuizou ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, por determinação do Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (fls. 315/320), a ordem foi concedida para o fim de reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD e, conseqüentemente, analisar o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena aplicada por outra espécie.

Recebo, pois, a determinação com efeito rescindente.

2.1.1Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 05/07 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 11/13) e definitivo (fls. 198/200 [LPTox]) e do laudo pericial telefônico (fls. 135/144 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Eliezer Robson dos Santos, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "nesta data estava de serviço com Sd Castro, em patrulhamento, quando avistaram um veículo Santana, de cor escura, transitando pela Rua Nove, esquina com a Rua Angelo de Quadros Bittencourt, e ao lado do carro havia um indivíduo e, quando perceberam a aproximação da viatura, o veículo rapidamente deixou o local e o indivíduo correu sentido contrário da via. Foi feito acompanhamento, sendo que a todo tempo ele estava com uma sacola e celular na mão, no cruzamento com a Rua Miguel Said Aydar ele tentou jogar a droga e o celular em um bueiro, mas caiu para fora. Correu novamente, sendo acompanhado e abordado em seguida, na Rua Nove, defronte número 10, onde ele estava tentando entrar, mas foi impedido pelos moradores. Retornaram ao local, sendo localizada a droga e o celular. Em busca pessoal, foi localizado dinheiro, mas ele não sabia dizer a quantia e disse ser R\$ 70,00, quando contabilizado, totalizou R\$ 130,00. O indivíduo já é conhecido dos meios policiais e saiu da cadeia semana passada, sendo que estava preso por tráfico de drogas, segundo ele declarou, saiu de HC. Questionado sobre a droga, disse que iria vender a droga para o "Rancho do Latinha", onde tem ocorrido "bailes funk". Questionado sobre o veículo Santana, disse que o condutor é conhecido por ALAN, vulgo "Titio", que segundo informações, seria o "dono da biqueira". Em verificação, constatou-se haver 10 pinos contendo cocaína e 15 porções de crack embaladas em papel alumínio". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Victor Paulo de Castro Pessoa, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "nesta data estava de serviço com Sd Castro, em patrulhamento, quando avistaram um veículo Santana, de cor escura, transitando pela Rua Nove, esquina com a Rua Angelo de Quadros Bittencourt, e ao lado do carro havia um indivíduo e, quando perceberam a aproximação da viatura, o veículo rapidamente deixou o local e o indivíduo correu sentido contrário da via. Foi feito acompanhamento, sendo que a todo tempo ele estava com uma sacola e celular na mão, no cruzamento com a Rua Miguel Said Aydar ele tentou jogar a droga e o celular em um bueiro, mas caiu para fora. Correu novamente, sendo acompanhado e abordado em seguida, na Rua Nove, defronte número 10, onde ele estava tentando entrar, mas foi impedido pelos moradores. Retornaram ao local, sendo localizada a droga e o celular. Em busca pessoal, foi localizado dinheiro, mas ele não sabia dizer a quantia e disse ser R\$ 70,00, quando contabilizado, totalizou R\$ 130,00. O indivíduo já é conhecido dos meios policiais e saiu da cadeia semana passada, sendo que estava preso por tráfico de drogas, segundo ele declarou, saiu de HC. Questionado sobre a droga, disse que iria vender a droga para o "Rancho do Latinha", onde tem ocorrido "bailes funk". Questionado sobre o veículo Santana, disse que o condutor é conhecido por ALAN, vulgo "Titio", que segundo informações, seria o "dono da biqueira". Em verificação, constatou-se haver 10 pinos contendo cocaína e 15 porções de crack embaladas em papel alumínio". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Negou a prática criminosa.

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a comercializar drogas há aproximadamente por 5 (cinco) meses [o que, no entender deste magistrado, denota habitualidade]. Por dificuldade financeira, decidiu fazê-lo. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

2.1.2Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da

Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo e guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.3 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se", de modo que, no presente caso dos autos, ao comparar os bens salvo (dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (saúde pública, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele (TJSP – 4ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 129/133), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente e (iii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis atractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, “enxugadores de gelo”, pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 [“Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido.”]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j.

22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara

Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1^a Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack - droga dentre as piores espécies que existem - como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ - Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ - Quinta Turma - AgRg no Habeas Corpus n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 01 [item III da ementa]; TJSP - 3^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP - 4^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP - 4^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP - 4^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP - 5^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP - 6^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 11/12; TJSP - 8^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP - 9^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP - 14^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500612-27.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 02/06/2022, p. 21/22 e 25 [cocaína]; TJSP - 14^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP - 15^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400,

da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – Habeas Corpus 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 05/06; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 19 [Boletim de Identificação Criminal] e 26 [Carteira de Identidade]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), e confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada a segunda circunstância com a terceira (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502532-07.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ FERNANDO VAGGIONE, V.U., j. 13/01/2021, p. 05; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002081-90.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 23/10/2020, p. 10; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000568-38.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 30/01/2019, p. 05; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000105-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CARDOSO PERPÉTUO, V.U., j. 14/02/2019, p. 06; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018), fixo a pena provisória,

com atenuação de 1/3 (um terço), em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância atenuante da jovialidade – a qual se refere à personalidade do agente, no entender deste magistrado – é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500451-65.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 02/02/2021, p. 09 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e o Superior Tribunal de Justiça (cf. item 2.1 desta sentença), por outro, reconheceu não existir prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que, em respeito à determinação com efeito rescintente (cf. item 2.1 desta sentença), fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Para a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD, exige-se, cumulativamente, que "o agente seja primário, de bons antecedentes [requisitos positivos], não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa [requisitos negativos]", de modo que, no entender deste magistrado, falta à parte ré um dos requisitos negativos (não se dedique às atividades criminosas), não se tratando, portanto, de traficante de primeira viagem, a considerar a reiteração do comportamento por aproximadamente 5 (cinco) meses antecedentes ao tempo do crime processado e julgado (cf. interrogatório da parte ré) (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 12/03/2020, p. 11 [três meses]; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005227-42.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. PAULO ANTÔNIO ROSSI, V.M., j. 02/10/2019, p. 26).

De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 209.023/MG – Rel.^a Min.^a CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, j. 19/11/2021, p. 08) e da determinação com efeito rescintente (cf. item 2.1 desta sentença), com o qual concordo, a utilização da natureza e da quantidade da droga (substância ou produto) na primeira fase e na terceira fase da fixação das penas, para definir a incidência e o percentual da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, caracterizaria o bis in idem.

Não desrespeitei, nesse ponto, o entendimento (fls. 220).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente

cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500483-90.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 18/01/2021, p. 11), porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002372-56.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 02/05/2020, p. 07), o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF)

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie; notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack) (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003045-83.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 29/08/2018; STJ – HC 414347 SP – Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – Dje 21/02/2018)

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN – V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA – V.U., j. 22/05/2014; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO – V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 – Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da

Comarca de Olímpia - V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 - Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia - V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP - Câmara Especial - Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 - Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), a considerar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade determinado (STF - Habeas Corpus n. 180.131/MS - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 12/02/2020, p. 07: "[...] eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado."); todavia, IMPONHO, porque identificados os critérios de necessidade e adequação (art. 282 do CPP), as seguintes medidas